硕士学位
论 文

建设工程承包人停工权研究

——以发包人违约为视角

覃卓君

廣西大學

二〇一一年六月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分类号 D922.297　　密级 公开

UDC

硕士学位论文

建设工程承包人停工权研究

——以发包人违约为视角

覃卓君

学科专业 民商法

指导教师 陈卫旗 副教授

论文答辩日期 2011年5月21日　学位授予日期 2011年7月1日

答辩委员会主席 张里安 教授

论文评阅人 孟勤国 教授　吴小英 教授　黄俊阳副教授

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

广西大学学位论文原创性声明和学位论文使用授权说明

学位论文原创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是在导师指导下完成的，研究工作所取得的成果和相关知识产权属广西大学所有。除已注明部分外，论文中不包含其他人已经发表过的研究成果，也不包含本人为获得其它学位而使用过的内容。对本文的研究工作提供过重要帮助的个人和集体，均已在论文中明确说明并致谢。

论文作者签名：[signature] 2011 年 6 月 15 日

学位论文使用授权说明

本人完全了解广西大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

本人保证不以其它单位为第一署名单位发表或使用本论文的研究内容；

按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；

学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；

学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；

学校可以公布论文的部分或全部内容。

请选择发布时间：

☑即时发布　　☐解密后发布

（保密论文需注明，并在解密后遵守此规定）

论文作者签名：[signature]　导师签名：[signature] 2011 年 6 月 15 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

建设工程承包人停工权研究
——以发包人违约为视角

摘　要

在建设工程施工活动中，承包人停工是常见现象。其中，当发包人违约时，承包人采取停工措施促使发包人纠正违约行为，维护自身的合法权益，对快速有效解决合同争议具有重大意义。现行法律法规对此类承包人停工权缺乏适当的规定，使该权利的行使在实践中遇到了障碍。笔者在处理类似法律纠纷时，深感厘清其中的法律原理和法律关系的重要性，因而本文拟对发包人违约情形下的承包人停工权进行研究。本文除引言和结语外共分为四章，分别从四个方面对本文论题进行相关论述。

第一部分介绍了建设工程承包人停工权的相关概念，并界定了发包人违约与承包人停工权的衔接点。第二部分分析了建设工程承包人停工权的法律属性。第三部分通过对我国建设工程承包人停工权现状的考察，指出现行规定的漏洞和不足。第四部分对我国建设工程承包人停工权制度进行了构建，从承包人停工权行使的原则、范围、构成要件、程序、主体及停工损失赔偿标准等方面对停工权的合理行使进行了研究，并藉此提出立法建议。

关键词：建设工程　承包人停工权　发包人违约　抗辩

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

CONTRACTOR'S ENTITLEMENT TO SUSPEND WORK ——THE EMPLOYER PERSPECTIVE OF BREACH OF CONTRACT

ABSTRACT

In building construction activities, Contractor workstoppage is a common phenomenon. Which, when the contract for breach of contract, the Contractor to lay-off measures to promotethe Employer rectify the breach, to safeguard their legitimaterights and interests of resolving contractual disputes quickly and efficiently is of great significance. Existing laws and regulations of such contractors the right of the lack of adequate provision for suspension of work, so that the exercise of the rights of the obstacles encountered in practice. The author in dealing with similar legal dispute, the legal principle which is deeply clarifying and legal importance of the relationship, which this article intends to contract the contractor for breach of contract case, the right to study the work stoppage. Addition to the introduction and conclusion, this paper is divided into four chapters, respectively, from four aspects of the related topics discussed in this article.

The first part describes the construction contract with the contractor for breach of contract related to the concept ofthe right suspension, and defines thecontractfor breach of contract with the contractor the right ofthe interface between suspension points. The second part of the Construction Contractor suspension of legal property rights. The third part through the suspension of the right ofthe Construction Contractor of the status of investigation, provided that the existing gaps and deficiencies。The fourth part of the suspension of construction contractors to build the right system, suspension from the contractor the right to exercise the principles, scope, components, procedures,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

subject, standard suspension damages and other aspects of the reasonable exercise of the right to lay-off has been studied and to put forward legislative proposals.

KEYWORDS: construction project; suspended the right of the contractor; employer breach; defense

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

前 言 1

第一章 建设工程承包人停工权概述 2

1.1 停工和停工权 2

1.2 发包人违约与承包人停工权的衔接点 3

1.2.1 承包人停工权存在的理论基础 3

1.2.2 承包人停工权存在的判断标准 4

1.3 建设工程承包人停工权的意义 5

1.3.1 维护公共利益 5

1.3.2 保障合同的履行 5

1.3.3 促进工程款的支付 6

第二章 建设工程承包人停工权的法律性质 7

2.1 建设工程承包人停工权性质的探讨 7

2.2 履约抗辩权和事实抗辩的区别 8

2.3 基于发包人不同违约情形区分为事实抗辩和权利抗辩 9

2.4 区分建设工程承包人停工权性质的意义 11

2.4.1 决定法官能否主动援引 11

2.4.2 对当事人的举证责任产生影响 12

2.4.3 体现立法者的价值判断 13

第三章 我国建设工程承包人停工权的现状与问题 15

3.1 《合同法》的规定 15

3.1.1 承包人停工权不规范 15

3.1.2 承包人行使停工权的范围过窄 15

3.1.3 承包人停工权性质未作区分 16

3.1.4 停工损失无统一赔偿标准 16

3.1.5 中止履行制度不完善 17

3.1.6 停工权限制的缺失 18

3.2 示范文本通用条款 18

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2.1 没有强制性 19
3.2.2 可停工范围过于狭窄 19
第四章 完善我国建设工程承包人停工权的构想 20
4.1 确定承包人停工权行使的原则 20
4.1.1 诚实信用原则 20
4.1.2 权利不得滥用原则 21
4.1.3 减损原则 22
4.2 完善承包人停工权的若干建议 23
4.2.1 扩大承包人停工权行使的范围 23
4.2.2 区分不同性质承包人停工权的实质构成要件 27
4.2.3 统一停工损失赔偿标准 29
4.2.4 规范承包人停工权行使的程序 32
4.2.5 对承包人停工权行使的主体不应扩张解释 33
4.3 立法建议 35
4.3.1 从《合同法》角度的立法完善 35
4.3.2 对相关配套规定的立法完善 36
结 语 37
参考文献 38
致 谢 40
攻读学位期间发表论文情况 41

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

前 言

建筑业是我国国民经济的支柱产业，近年来，我国经济的飞速增长促进了建筑业的蓬勃发展，与此同时，建筑业的诚信缺失也日益成为一个严重的社会问题，其中，发包人拖欠工程款的现象最为突出。在实践中，面对发包人的种种违约行为，承包人常常采用停工的方式予以对抗，停工权作为一种私力救济方式具有及时、有效的优点。但我国法律对承包人停工权的规定颇为简单，可操作性差，致使停工权的行使出现了惧用和滥用的双重局面：一方面，有些承包人因不了解如何行使停工权，害怕抗辩不成反成违约，不敢贸然行使停工权；另一方面，有些承包人则将停工权当成要挟发包人满足其要求的法宝。目前，国内对建设工程承包人停工权的研究并不多见，现有的研究成果普遍将承包人停工权视为建设工程合同履行抗辩权等同对待，仅在建设工程合同履行抗辩权的论述中对其稍有提及。本文以发包人违约前提下的建设工程承包人停工权为研究对象，通过对发包人违约与承包人停工权的衔接点进行界定，厘清承包人停工权的法律属性，并从现行法角度分析承包人停工权行使的障碍，最后着重对完善承包人停工权制度提出建议，以期解决当前实践中遇到的难题。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章 建设工程承包人停工权概述

1.1 停工和停工权

所谓停工，顾名思义即停止工作的意思。我国法律没有直接出现“停工权”一词，但在与建设工程相关的法律法规里，我们可以看到“有权停止作业”、“有权责令停止建设”、“有权立即停止作业”等字眼。而在建设工程施工实践过程中，建设行政主管部门、建设单位、监理单位、施工单位都有可能为了保护某种特定利益而下令暂时停止施工或暂时采取停工措施。因此，广义的停工权可以理解为使工程暂时停止建设的权利，包括要求暂时采取停工措施和暂时采取停工措施的权利。狭义的停工权则指施工主体暂时采取停工措施的权利。

我国《合同法》第二百六十九条规定，“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同”，因此，在建设工程合同履行过程中的“停工”指的是承包人停止工程建设的意思，而“停工权”从字面上理解即为停止工程建设的权利。据此，本文涉及的建设工程承包人停工权指的是承包人依据合同约定或法律规定的条件和程序暂时停止施工的权利。

建设工程是一类较为特殊的经济活动，具有以下特点：第一，投资额度大。建设工程作广义解释时，包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备工程，包括各类建设工程的新建、改建、扩建等。[1]由于建设工程产品的特殊性，往往需要投入大量建设资金，如2008年北京奥运会场馆建设在130亿元左右，目前世界上最大单体建筑——北京首都国际机场T3航站楼，总投资达到了270亿元。第二，建设周期长。因建设工程涉及多个环节、多道工序、多个主体，建设周期往往少则一、二年，长则五、六年，如我国三峡水电站计划建设周期则长达9年。第三，参与主体多样。建设工程的建设过程大体上经过勘察、设计、施工三个阶段，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位成为参与建设工程活动最基本的主体。其中，施工单位又涉及总包人、分包人、实际施工人等多个主体。第四，风险因素多。由于建设工程投资大、周期长，在建设过程中往往会遭遇各类风险。其中包括气候条件、自然灾害、战争骚乱等不可抗力事件，还

[1] 《建设工程质量管理条例》第2条规定，“凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守本条例。本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

包括政策变动、经济危机、资信下滑、破产倒闭等人为因素风险。第五，公益性强。建设工程是人们日常生活和生产、经营、工作的主要场所，是人类生存和发展的物质基础。建设工程的质量，不但关系到生产经营活动的正常运行，也关系到人民生命财产安全。[2]此外，建设工程在建设过程中，还会对周边的公共安全、卫生、环境、交通等产生一定影响。

上述特点决定了建设工程活动中不可避免地出现矛盾和纷争，如果将解决建设工程合同争议的办法局限于追究违约责任或解除合同，将会使合同双方当事人付出高昂的成本。因此，建设工程中的“停工权便成为促进建设工程履行，克服各类合同和法律障碍，纠正各类违约及违法行为的有效手段”。[3]

1.2 发包人违约与承包人停工权的衔接点

1.2.1 承包人停工权存在的理论基础

发包人违约时，承包人停止施工，并有权顺延工期和赔偿停工损失，这在各国的法律、判例和格式合同文本中都有表现。如英国 1996 年颁布了《HGCR Act》其中第 112 条规定，当付款义务人未按照合同约定的时间及数额完全支付且未发出有效延期支付的通知时，受款人在不损害其他权利的情况下，有权暂停履行其合同项下对付款义务人的合同义务。[4]FIDIC[5]《土木工程施工合同条件》（1999 年第一版）（以下简称 FIDIC 合同条件）第 16.1 条【承包商暂停工作的权利】规定：“如果工程师未能按照 14.6 款【期中支付证书的颁发】开具支付证书，或者雇主未能按照 2.4 款【雇主的资金安排】或 14.7 款【支付】的规定执行，则承包商可在提前 21 天以上通知雇主，暂停工作（或降低工作速度），除非并且承包商收到支付证书，合理的证明或支付（视情况而定并且遵守通知的指示）。”我国《合同法》第 283 条也规定了发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工期和要求赔偿停工损失。

发包人违约与承包人停工，表面上都属于违法行为，根据法的一般原则应按双方违

[2]《建设工程质量管理条例释义》，中国城市出版社

[3] 谭敬慧．建设工程承包商“停工权”问题研究（硕士论文）[D]．北京：中国政法大学，2008.

[4] Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996

[5] FIDIC 是国际咨询工程师联合会(Fédération lnternationale Des lngénieurs Conseils)的法文缩写，该会编制的《业主与咨询工程师标准服务协议书》（白皮书）、《土木工程施工合同条件》（红皮书）、《电气与机械工程合同条件》（黄皮书）、《工程总承包合同条件》（桔黄皮书）被世界银行、亚洲开发银行等国际和区域发展援助金融机构作为实施项目的合同协议范本。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

约处理，法律允许发包人违约时承包人享有停工权，是否有厚此薄彼之嫌？事实上，在发包人违约的情形下，承包人停工权与违约责任、解除合同一样属于一种救济手段，它的存在是为了平衡发包人与承包人的利益，起到止纷定争的作用。

笔者认为，承包人停工权存在的基础是双务合同的牵连性理论，所谓双务合同的牵连性，是指在双务合同中，一方的权利和另一方的义务之间相互依存、互为因果的关系，[6]具体可分为发生上的牵连性、功能上的牵连性和存续上的牵连性。发生上的牵连性指一方的给付与相对人的对待给付在发生上互相牵连，即一方的给付不发生时，相对方的对待给付义务也不发生。功能上的牵连性又称履行上的牵连性，是指双务合同的当事人一方所负给付与相对人所负对待给付互为前提，一方不履行其义务，相对人原则上亦可不履行。存续上的牵连性则指双务合同一方当事人的债务因不可归责与双方当事人的事由，致不能履行时，债务人免除给付义务，债权人亦免除对待给付义务。[7]承包人停工权正是这种功能上的牵连性的反映，其存在有双重功能：保护己方的债权；迫使对方履行合同。承包人停工权借此两种功能，促使双方当事人履行自己的合同义务，保障合同的切实履行。

1.2.2 承包人停工权存在的判断标准

发包人违反的合同义务与承包人的施工义务是否具有牵连性是承包人停工权得以存在的基本判断标准，根据上述双务合同牵连性的具体表现可以细分为两个具体标准：

第一个标准，发包人违反的合同义务是否与承包人的施工义务构成发生上的牵连性。发包人的合同义务是承包人施工义务发生的前提条件，如果发包人不履行合同义务，承包人会因此发生履行不能，导致施工暂停。因此，发包人违反的合同是否为承包人施工义务的前提或先决条件是判断承包人停工权存在的另一个标准；

第二个标准，发包人违反的合同义务是否与承包人的施工义务构成功能上的牵连性。建设工程合同成立后，合同双方基于合同各负履行义务，发包人负担义务以承包人负担义务为前提，如果发包人不履行合同义务，承包人的权利不能实现，其义务的履行就会受影响。因此，发包人违反的合同义务是否影响承包人合同目的实现是判断承包人停工权存在的另一个标准。

[6] 马俊驹，余延满．民法原论[M]．北京：法律出版社，2007：580
[7] 崔建远主编．合同法[M]．北京：法律出版社，2007：131

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.3 建设工程承包人停工权的意义

1.3.1 维护公共利益

如前所述，建设工程活动与公共利益有着密切的关联性，因此，各国法律法规都明文规定了建设工程活动参与主体的各种法律义务，此类义务的作用在于维护建设过程中的公共交通、公共卫生、公共安全等社会公共利益及确保工程的质量和安全。某些时候此类法律义务也会转化成合同义务，如我国《建筑法》第五章“建筑安全生产管理”第42条规定，建设单位需要临时停水、停电、中断道路交通的或需要进行爆破作业的，应当按照国家有关规定办理申请批准手续；而《99版施工合同》“通用条款”第8条发包人工作也规定了，发包人要按合同专用条款约定的时间办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。如果发包人违反此类义务，导致施工行为损害了公共利益或造成危险状态，相关的行政主管部门有权依据法律的规定责令停工，并要求发包人纠正其违法行为。但是，行政处罚在实践操作中具有滞后性的一面，往往是待行政主管部门发现其违法行为时，已经给公共利益造成了不良影响，甚至是难以挽救的后果。而此时赋予承包人停工权，可以在违法行为发生的第一时间内对其进行有效阻止，最大限度地维护公共利益。

1.3.2 保障合同的履行

对于建设工程施工合同的双方当事人而言，其履行合同的主要目的都是为了获得合同的预期利益，而解除合同、追究违约责任不是合同当事人所期待的结果。因为建设工程进入施工阶段后，施工合同双方都投入了大量的人力物力，合同一旦被解除，将会给双方造成巨大的经济损失。对于发包人来说，如果工程做到一半，合同解除，承包人退场之后，后继施工队伍的工程很难衔接，工程的工期、质量都会受到很大的影响；对于承包人来说，中途退场之后仍然要对已完工部分的工程承担保修责任，但由于工程构造的复杂性，其质量责任很难区分，此时承包人将面临成为“替罪羊”的风险。此外，工程中途结算也是一件困难的事情，承包人一般尽量避免此类事情的发生。

但是如若发包人违约后，承包人从经济的角度出发，不愿意解除合同，那只能将矛盾积攒到工程完工后再行起诉，但这样一来，承包人就可能错失了解决问题的最佳时机，并为此付出高昂的诉讼成本。因此，停工权的存在给予承包人采用积极的方法解决合同

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

履行中的障碍的可能性，承包人行使停工权，可以敦促发包人纠正其违约行为，排除合同履行中的障碍，化解纠纷，避免解除合同的不利后果发生，保障合同的持续履行。

1.3.3 促进工程款的支付

工程款拖欠问题是我国建设工程领域一个普遍存在的现象，近年来，该现象呈现愈演愈烈之势，已经严重阻碍了建筑业市场的健康发展、损害了广大人民群众的根本利益，直接影响了社会的稳定。党和国家领导人对此非常重视，并先后作出重要批示，要求对此社会问题进行综合整治。为解决工程款拖欠问题，1999 年颁布的《合同法》第 286 条特别规定了建设工程款优先受偿权，2002 年最高人民法院针对该条规定作出了《关于建设工程价款优先受偿权的批复》，但该制度旨在一次性解决工程欠款，对施工过程中的进度款拖欠问题根本无力解决，此外，鉴于我国建筑行业的特殊国情，该制度在实践中可谓收效甚微。由于工程款拖欠问题在法律上难以找到出路，只好依赖于行政措施，但行政手段并非制度化的规范，其自身存在一定的局限性，因此并未能从根本上解决工程款拖欠问题，建筑企业被拖欠的工程款总额仍然呈逐年递增的趋势。

面对法律政令的无力，实践中承包人常常使用停工的方式促使发包人支付工程款，而承包人这一举措得以奏效的主要原因，是因为时间节点的要求对于发包人（尤其是开发商）来说犹如生命线。首先，发包人的银行贷款是与工程进度直接挂钩的，因此正常的项目进展，才能够保证发包人稳定的资金供给链；其次，国家对于项目开发的销售有诸多的限制，比如住宅楼的预售条件是主体结构必须完成 2/3，进度如果不能保证，其结果就是直接导致开发商资金回笼时间受影响；第三，一般来说，项目开发都会有一个承诺使用的日期，不论是住宅这种产权二次交易还是基础设施对公众的承诺，投入使用日期的推迟对于发包人来说都会非常被动。房产开发商可能要面临众多业主的索赔，而政府工程领导就可能承担公众谴责的风险而导致仕途受损。投入使用最终日期的完成，都是由中期节点完成来保证的，所以发包人会对承包人工程进度特别关注。

在国际上，承包人以行使停工权的方式解决工程款拖欠问题也已成为一种惯例，许多国家都颁布了专门的建筑行业支付法令保障工程现金流，并赋予承包人停工权。承包人停工权的行使，使承包人获得了与发包人平等对话的机会，促使发包人按时支付工程进度款，从而维护了承包人依法获得工程款的合法权益，从根本上解决工程款的拖欠问题。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章 建设工程承包人停工权的法律性质

2.1 建设工程承包人停工权性质的探讨

关于建设工程承包人停工权的法律性质问题，我国通说认为建设工程承包人停工权属于履约抗辩权，[8]笔者认为此观点有待商榷，理由如下：

第一，某些情形下的停工权并不具备履约抗辩权的特征。

履约抗辩权属于抗辩权的一种，抗辩权是对抗请求权的权利，以请求权存在为前提。双务合同中的履约抗辩权需以债权人对债务人享有可以实现的请求权为前提，如果该请求权不合法或客观不可能实现，则应视为请求权不存在。例如，合同约定发包人于2010年2月1日交付设备，承包人于2010年2月2日开始设备的安装，但发包人到期未能交付设备，此时发包人对承包人不享有要求施工的请求权，因为发包人未交付设备之前承包人的合同义务不具备可执行性。此种情形下，承包人行使停工权并不具备履约抗辩权的特征，笔者认为此时的停工权应为事实抗辩。

第二，将承包人停工权全部界定为履约抗辩权会造成权利的滥用。

履约抗辩权存在的基础在于双务合同的牵连性，基于双方合同义务的内在牵连性，履约抗辩权的成立并不要求债权人的违约与债务人不履行合同义务具有实质上的因果关系，即并不强调只有当债权人不履行合同义务致使债务人无法履行合同义务时，债务人才享有抗辩权。以我国《合同法》67条规定的先履行抗辩权为例，只要债权人未履行其在先的合同义务，债务人即可以拒绝履行其在后的合同义务。例如，合同约定发包人于2010年2月1日交付设备，承包人于2010年2月2日开始设备的安装，发包人到期未能交付设备，此时若根据先履行抗辩权的规定，承包人可以发包人未提供设备行使停工权并顺延工期。但事实上，承包人由于土建部分工程未完工，至2010年2月2日仍不具备设备安装的条件，发包人未按期提供设备并没有对承包人造成任何影响，此时若根据先履行抗辩权的成立要件支持承包人的停工权显然有失公平。笔者认为，造成以上局面的原因在于建设工程承包人的某些停工权不具备履约抗辩权的性质，不应适用履约抗辩权的构成要件，否则将会导致停工权的滥用。

第三、将承包人停工权全部界定为履约抗辩权会导致裁判不公。

[8] 参见党伟．建筑工程承包商停工权权利属性分析[J]．人民司法，2006（4），谭敬慧．建设工程承包商“停工权”问题研究（硕士论文）[D]．北京：中国政法大学，2008.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

履约抗辩权对于债务人而言是一种自我保护手段，是为了避免自己履行后得不到对方履行的风险，这一权利的存在，可以使对方迫于压力及时履约或提供担保，从而实现对自己债权的担保作用。抗辩权的存在以主张为生效要件，[9]这样的效力体现在诉讼模式上表现为法官不能主动援引。例如，合同约定发包人于2月1日交付施工图，承包人于3月1日竣工，3月1日过后，双方均未履行。发包人起诉至法院要求承包人履行并承担违约责任，那么试问，当承包人缺席时，法院在查明上述情况后应否驳回发包人的诉讼请求？

依据履约抗辩权需主张才生效的理论，这一抗辩是承包人的权利，若承包人缺席，视为其放弃了主张抗辩的权利，法院得以判决承包人履行施工义务并承担违约责任。但是，显然这样的判决对承包人来说是不公平的，也是无法强制执行的，因为承包人施工需以发包人提供图纸为前提，发包人未提供图纸致使承包人客观上无法进行施工。发包人未履行合同义务致使承包人履约不能，承包人享有的应该是抗辩而非抗辩权。

通过以上的分析，我们不难发现，在某些情形下，当我们运用履约抗辩权的理论去规范承包人的停工权时，其效果并不尽如人意，反而会导致事实与结果的偏差。造成这种局面的原因，主要是因为某些情形下的承包人停工权并不表现为履约抗辩权，它们实际上属于事实抗辩，如果强行将其作为履约抗辩权进行调整，必然会产生排异现象。有鉴于此，笔者认为应当将承包人行使停工权的行为区分为行使履约抗辩权和事实抗辩，还原其本来面目，适用不同的法律规范对其进行调整。

2.2 履约抗辩权和事实抗辩的区别

履约抗辩权又称合同履行抗辩权，我国《合同法》第66、67、68条分别规定了同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安履行抗辩权三种履约抗辩权，履约抗辩权是一项具体的抗辩权制度，其本质上属于权利受限制的抗辩，即权利抗辩。

权利抗辩和事实抗辩都属于广义的抗辩。罗马法中的抗辩，作为被告的辩护手段，是法律尤其是裁判官赋予被告的、据以对抗原告诉权的权利，包括欺诈抗辩、胁迫抗辩、同时履行抗辩、未准确履约抗辩、特定事物抗辩、既定简约抗辩、钱款抵销抗辩和保证

[9] 关于抗辩权生效的前提目前理论界有三种主张：第一种认为存在即生效，支持这一观点的是德国学者施洛瑟；第二种观点认为主张才生效，德国和我国台湾地区通说采此观点；第三种观点认为应该对抗辩权的本体效力和附随效力实行不同的规则，持此观点的有史尚宽、郑玉波等。我国通说采主张才生效。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人先诉抗辩等。[10]19 世纪潘得克吞学派将实体法从诉讼法中分离出来，抗辩也被明确划分为实体法上的抗辩和程序法上的抗辩。实体法上，德国学者围绕权利的效力，把抗辩划分“事实抗辩”和“权利抗辩”，事实抗辩指的是权利妨碍的抗辩、权利消灭的抗辩，权利抗辩则指权利受制的抗辩。

此后，随着权利学说研究的进一步深入，“权利抗辩”被赋予一个全新的名称，即“抗辩权”。抗辩权概念有其特定的含义，它并非笼统地指代一切进行抗辩的权利，而是特指这样一个法律现象：抗辩事由对请求权的形成产生阻碍，但并不消灭该请求权，因此权利人可以自由决定是否主张抗辩的效果。换而言之，抗辩权对抗请求权却并不消灭请求权，抗辩权是被请求人对请求人享有的拒绝给付的权利，当请求权人行使权利时，义务人就可以行使抗辩权拒绝给付，起到阻却违法、平衡权利人与义务人利益的作用。[11]我国民法上的抗辩权种类主要有履约抗辩权和保证人的先诉抗辩权。

事实抗辩和权利抗辩（履约抗辩权）对抗的内容不同，前者是对特定事实发生的抗辩，其对抗的内容是：对方的权利尚未发生或者对方的权利虽然曾经发生过，但已因某种事由而消灭；后者是请求权的对抗权，即对权利发生的抗辩，其对抗的内容是：虽然对方的请求权存在，但可以依据抗辩权享有拒绝给付的权利。此外，在是否需要当事人自行主张方面也存在不同，诉讼中，事实抗辩无需当事人主张，法官可主动援引，而权利抗辩则不能由法官主动援引。

2.3 基于发包人不同违约情形区分为事实抗辩和权利抗辩

在建设工程施工合同中，发包人的合同义务种类繁多、形态各异，发包人违反不同的合同义务，对承包人的履约状态产生不同的影响。就发包人的合同义务与承包人施工义务是否互为实现的前提条件来看，发包人的合同义务大致可以分为两类：第一类，发包人的合同义务是承包人进行施工的前提条件，如果发包人违反此类义务，会导致承包人客观上的履行不能；第二类，发包人的合同义务不是承包人进行施工的前提条件，如果发包人违反此类义务，不会导致承包人客观上的履行不能，但会影响承包人合同利益的实现。

发包人违反上述两种类型的合同义务，承包人得以停工，表面上看都是因为发包人的违约行为导致了承包人的停工，但承包人对发包人违约采取停工措施的价值基础却有

[10] 黄风．罗马法词典[M]．法律出版社，2002： 106～108
[11] 尹腊梅．民事抗辩权研究[M]．北京：知识产权出版社，2008：89

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

所不同：在前一种情形，承包人因发包人的违约发生客观的履行不能，承包人得以否认自己的施工任务行使停工权，此种情形属于事实抗辩；在后一种情形，承包人因发包人违约，致自身的合同利益无法实现，为避免交易的风险，拒绝履行己方的合同义务，此种情形属于权利抗辩。

在前一种情形下，发包人履行合同义务是承包人履行合同义务的前提或先决条件，例如发包人必须交付图纸，承包人才得按图施工，发包人按时交付图纸是承包人得以按时按质交付工程的先决条件。当发包人违反此类作为前提或先决条件的合同义务时，承包人得以停止施工，此时承包人行使的停工权虽然具有抗辩的性质，但不属于真正意义上的权利抗辩（抗辩权）。抗辩权的存在必须以有可以实现的对待给付为前提，因为抗辩权是被请求人对请求人享有的拒绝给付的权利。[12]而发包人向承包人享有按时按质交付工程的请求权以其履行了自己的合同义务为先决条件，当这一先决条件缺失时，他对承包人的债权只是一个尚未产生请求权的债权，换言之，是一个不可强制执行的债权，此时承包人行使停工权属于事实抗辩。

在后一种情形下，发包人合同义务的存在是为了实现承包人的合同利益，违反此类合同义务不会导致承包人客观的履行不能，即不会必然导致承包人无法施工。但承包人为了维护自己的合法利益，避免己方履行后得不到对方履行的风险，可以选择通过行使停工权，发挥防范信用风险，增益债权实现的功能。例如在合同约定垫资施工的情形下，发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人可以暂停下一阶段施工，以促使发包人履行自己的合同义务。承包人此时行使停工权并不否认发包人要求其施工的权利的存在，但当停工事由出现时，得以拒绝发包人的履行要求，待停工事由消失后再行复工。因此，发包人违反了此类合同义务，承包人得以停工的权利系履约抗辩权，属于权利抗辩的性质。

针对合同履行的不同顺序，我国《合同法》第 66、67、68 条分别规定了同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权，[13]而建设工程施工合同在不同的阶段有不同的履约顺序，因此承包人停工权在不同的施工阶段也表现为不同的履约抗辩权。以发包人欠

[12] 尹腊梅．民事抗辩权研究[M]．北京：知识产权出版社，2008：89

[13] 《合同法》第 66 条规定："当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。"
第 67 条规定："当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。"
第 68 条规定："应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：㈠经营状况严重恶化；㈡转移财产、抽逃资金，以逃避债务；㈢丧失商业信誉；㈣有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。"

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

付工程款为例，承包人在不同阶段行使停工权需要援引不同的法律依据。在实践中，发包人的工程款主要分为开工阶段的预付款、施工过程中的进度款和工程完工后的结算款，根据上述付款性质不同施工合同可以划分为支付工程预付款阶段、支付进度款阶段和支付结算款阶段。在支付工程预付款阶段，发包人支付预付款是先履行义务，发包人不按约支付工程预付款，承包人可以停止施工，此阶段的承包人停工权具有先履行抗辩权的性质。在支付进度款阶段，由承包人先施工，发包人后付款，如发包人未按约定支付进度款的，承包人也可以依据先履行抗辩权停止下一阶段的施工任务。因为建设工程施工合同属于连续性的合同，继续性合同为单一合同，当事人若未履行某期次的债务，就构成整体合同的一部分不履行。于此场合，对方当事人应当享有抗辩权。[14]

根据以上的分析，我们可以得出这样的结论：发包人违反了作为承包人履约前提或先决条件的合同义务时，承包人行使的停工权以否认自己的施工义务为内容，在学理上属于事实抗辩，属于广义的抗辩的一种；发包人违反了不作为承包人履约前提或先决条件的合同义务时，承包人行使停工权并不否认自己的施工义务，但可以拒绝履行，在学理上属于权利抗辩，或称抗辩权，此类抗辩权在我国法律上规定为履约抗辩权。

2.4 区分建设工程承包人停工权性质的意义

民事权利是有民法规定和保障的主体以相对自由的作为或不作为的方式获得利益的一种手段，是民法规范赋予当事人为实现其利益所可实施的行为范围。[15]权利的基础是利益，权利乃法律所承认和保障的利益。不管权利的具体客体是什么，上升到抽象概念，对权利主体来说，它总是一种利益或必须包含某种利益。[16]法律对民事权利的保护依其实现的利益不同而呈现出不同的价值判断标准，从而影响其保护的方式，进而决定其立法取向。区分发包人不同违约情形下承包人停工权的性质，即区分那种情形下属于事实抗辩，哪种情形下属于抗辩权，在理论和实务上具有重大的意义，主要体现在三个方面。

2.4.1 决定法官能否主动援引

“今天，实体法上最重要的一个问题，是要分清楚某种辩护手段应自动产生效力，

[14] 白李京法. 继续性合同基础理论研究（硕士论文）[D]. 北京：清华大学，2003.
[15] 柳经纬主编. 民法总论[M]. 厦门：厦门大学出版社，2005：56
[16] 张宏生、谷春德主编：《西方法律思想史》，北京大学出版社 1990 年版，第 353-355 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

还是仅仅依据被告的相关愿望才产生效力。”[17]事实抗辩的产生基于请求权的消灭，因此在诉讼中只要法官从双方的陈述中知晓抗辩事实的存在，哪怕被告没有主张，法官也应当主动援引，以作出对被告有利的裁决，法官的主动援引源于其对诉的正当性审查的义务。而抗辩权是需要主张的抗辩，它是对已经存在的请求权发生对抗的权利，如被告没有主张此抗辩，法官不得主动引用抗辩事实驳回原告的请求。

例如，施工合同约定发包人于1月5日交付图纸，承包人于2月5日完成施工。至1月5日发包人未能交付图纸，承包人停工至2月5日未能完成施工，此时发包人仍未交付图纸。发包人于2月6日起诉至法院，要求承包人履行合同并承担违约责任，假设承包人未到庭参加诉讼，不能表达抗辩主张，此时法官能否依据查明的事实作出对发包人不利的判决？根据上述关于停工权性质的分析，我们知道此种情形下承包人的停工权属于事实抗辩，法官可以主动援引抗辩事实驳回发包人的诉请。反之如果案件涉及的停工权属于抗辩权的性质，则被告必须对自己的抗辩权进行主张，否则视为放弃，法官可以作出对被告不利的判决。

2.4.2 对当事人的举证责任产生影响

在事实抗辩的情形下，承包人提出抗辩的理由是因为发包人的违约行为导致自己无法履行合同义务，因此发包人在纠正自身的违约行为之前，不得要求承包人履行合同义务，因为此时的合同义务是未发生的，不具备执行力的。但如果发包人能够举证证明其未履行合同义务并没有影响到承包人的履约能力，此时承包人的抗辩就会不成立。例如，施工合同约定发包人于4月10日向承包人交付电梯设备，5月10日承包人需完成全部工程。4月10日电梯井的土建工程未完成，直至4月15日承包人完成电梯井的土建工程具备安装电梯的条件，发包人同时交付了电梯设备，承包人得以进行电梯安装，此后承包人于5月15日完成工程。如发包人起诉至法院要求承包人承担逾期完工的责任，承包人是否得以发包人未按时交付电梯设备致使其安装工程停工，从而主张工期顺延？笔者认为法院应当判决承包人承担逾期完工的责任。因为，如果假设合同约定承包人安装电梯的开始时间为4月10日，则电梯安装部分的工期为30天，其从4月15日开始施工，至5月15日完工，工期没有改变，但其土建部分逾期交工的责任是不能免除的；如果假设合同约定承包人的安装电梯的开始时间为4月15日，则电梯安装部分的工期

[17] [德] 迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论[M]. 邵建东，译. 北京：法律出版社，2001：82.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为25天，承包人5月15日才完工，已经超过工期5天，毫无疑问需要承担违约责任。虽然发包人没有按期交付电梯设备，但发包人的此项延误并没有导致承包人的电梯安装工作停止，因此承包人没有理由主张停工权，并据此要求顺延工期。所以，承包人要主张停工权成立，必须要证明发包人的违约行为已经构成了对其履约的阻碍，或者发包人能够提供证据证明承包人的停工并非由其违约引起的，则可以消灭承包人的抗辩。

而在权利抗辩的情形下，承包人行使停工权以发包人未履行合同义务为理由，而不问两者之间的合同义务是否互为履行条件，即只要发包人履行合同义务不符合约定，承包人便可以行使停工权。所以，此时承包人只要能够证明发包人没有按照合同的约定履行其义务，其抗辩便可以成立。例如，合同约定发包人于1月10日支付工程备料款，但到期未支付，承包人行使先履行抗辩权停工。发包人了解到承包人已经赊购到材料，价款支付时间为1月20日，其能否以逾期提供资金并未造成承包人无法备料主张承包人的停工权不成立？答案是否定的，因为履约抗辩权制度着眼于对当事人的交易提供安全保障，防止己方履行后得不到对方履行的风险，如果发包人的违约行为影响了承包人合同利益的实现，对承包人产生信用危机，承包人即可以行使停工权。

2.4.3 体现立法者的价值判断

“如果某项法律行为是完全正确的，那么法律就不对该行为加以限制，使之成为一项没有任何抗辩或者抗辩权附着的权利；如果立法者严格否认某种法律行为的合法性，就可以采取抗辩的模式，规定因这种非法行为而产生的请求权自始不得发生，或者可以被撤销自始不具有效力；如果某项法律行为的效力处于前二者之间，则可以设置为附有抗辩权的行使。”[18]

基于事实抗辩行使的停工权，承包人提出抗辩的前提是明确的，即发包人的违约已导致承包人无法履约，因此即便法律没有完整地罗列出所有事实抗辩的情形，承包人也能依据实际情形予以抗辩。但基于履约抗辩行使的停工权则不能依据事实来判断，只能由法律来规定，换句话来说，作为履约抗辩权的停工权必须有法律的明确规定为前提。因此，相对于事实抗辩情形下的停工权而言，立法者需要更谨慎地对待履约抗辩情形下的停工权。

根据传统履约抗辩权的理论，发包人不履行主给付义务的，承包人可以拒绝履行其

[18] 尹腊梅．民事抗辩权研究[M]．北京：知识产权出版社，2008：83．

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

主给付义务，即停止施工。但发包人不履行从给付义务的，承包人是否亦可以行使停工权？在哪些情形下可以行使停工权？这些就需要有明确的法律的规定，而立法者也需要充分考虑发包人哪些违反从给付义务的行为影响了承包人合同目的实现，但又不必然导致合同无法履行，在此种情形下赋予承包人抗辩权，由其自由选择是否停工。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 我国建设工程承包人停工权的现状与问题

从理论上来说，承包人停工权的意义非常重大，但在实际的施工活动中，承包人停工权的行使情况却不尽如人意，除了管理问题和行业潜规则等因素所致，法律上的缺陷也难逃其咎。

3.1 《合同法》的规定

有学者认为，建设工程承包人停工权的法律依据主要存在现行的《合同法》第66、67、68条和第278、283条，《合同法》第66条规定的同时履行抗辩权、第67条规定的后履行抗辩权和第68条规定的不安履行抗辩权是承包人停工权的理论依据；《合同法》第十六章《建设工程合同》第278、283条是承包人停工权的具体规定。笔者认为，虽然《合同法》中存在对建设工程承包人停工权间接性的规定，但仍存在以下缺陷：

3.1.1 承包人停工权不规范

我国《合同法》第278条规定："隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失"，第283条规定："发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失"。上述两条文规定了发包人未履行合同义务的，承包人可以顺延工期和索赔损失，虽然未直接出现"停工权"或"可以停工"的措辞，但学术界和实务中通常将其理解为间接规定了"停工权"。

法律上没有明确规定停工权，致使在实践操作中许多在一线工作的施工管理人员对上述条文的理解产生了歧义，为数不少的承包人认为《合同法》第278、283条规定的是工期和损失的索赔，并理所当然地认为只要发生上述事由，承包人便可以在结算时要求工期和费用索赔，而不知道上述两项索赔须建立在停工的基础上，完全忽视了及时行使停工权的重要性，最后导致索赔失败。

3.1.2 承包人行使停工权的范围过窄

《合同法》第278、283条规定了承包人可以行使停工权的范围包括发包人未及时

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

检查隐蔽工程，未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等情形，笔者认为法律采用列举的方式来划定承包人行使停工权的范围有其局限性。首先，在建设工程合同中，发包人除了提供资金这项主给付义务外，还有很多种类繁多、名目繁杂的合同义务，这是由建设工程合同的复杂性决定的；其次，建设工程合同的履行周期长，各种变动因素交织其间，发包人的合同义务也会随着合同的履行产生变化。因此，上述《合同法》规定的六种情形根本不足以涵盖承包人停工权的所有事由，如果不加以调整，将会导致实践操作中出现无法可依的局面。

3.1.3 承包人停工权性质未作区分

《合同法》列举了承包人可以停工的情形，但未对不同性质的停工权予以区分。从现行的规定来看，只要发包人未按照合同履行法律列举的义务，承包人便可以停工，但事实上，不同情形下承包人行使停工权的要件是不同的。对于事实抗辩情形下的停工权，应建立在发包人的违约行为阻碍了承包人履约能力的前提下，即强调发包人的违约导致了承包人不能施工。在某些情形下，发包人违反了合同义务，但未影响承包人履约的，则承包人不能停工，否则将损害发包人的利益。但在权利抗辩的情形下，发包人只要到期未履约，承包人便可以停工，而不问是否造成了承包人的履约不能。因此，《合同法》没有区分不同停工权的构成要件，将所有的停工事由作同一规定，容易导致实践操作中出现偏差。

3.1.4 停工损失无统一赔偿标准

承包人依据法律的规定行使停工权后，可以获得法律给予其的救济，即顺延工期和获得停工损失赔偿，但关于停工损失包含哪些具体项目，各个项目如何计算，目前我国法律没有统一的规定。

我国《合同法》第 278、283 条规定了发包人违约的，承包人有权要求赔偿停工损失，同时第 284 条又规定，发包人违约导致工程中途停建的，应当赔偿承包人因此造成的停工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。通常我们将第 278、283 条规定的停工损失理解为停工期间发生的一切损失，但第 284 条却将停工损失与倒运、机械设备调迁、材料和构件积压损失置于并列的位置，这样一来就令“停工损失”变得更令人难以琢磨。因为根据常理，倒运、机械设备调迁、材料和构件积压损失都是停工期间的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

具体损失项目，如若它们都不属于“停工损失”，那么“停工损失”是否另有其他所指？

关于停工损失所包含的具体项目，我国没有统一的规定，各省市的地方规定也不够明确。具体到各个项目来看，也会存在量和价的争议，通常单价可以参照当地定额造价管理部门的行业规定，但量却只能依靠现场签证，可是一旦发生争议停工，发包人一般都会拒绝签证。这样一来，承包人的停工损失根本无法计算，而获得停工期间的损失赔偿对于承包人来说却意义重大。因为承包人一旦停工，并不会立即解散工地遣散人员，在停工期间承包人仍然需要支出人员工资、机械设备租赁、材料仓储保管等各项费用，期间还会面临材料涨价、贷款利息增加等风险，这些都属于承包人额外费用的支出。如果承包人停工期间的损失不能得到保障，那么其行使停工权就变得毫无意义，甚至是得不偿失。一个理性的承包人在行使停工权这一抗辩武器时，必然首先要考虑这一行为的后果，权衡得失之间的利弊。由于法律缺乏对停工损失的明确规定，增加了承包人行使停工权的风险，使承包人产生惧用的情绪，最后只会导致该权利成为一介摆设。

3.1.5 中止履行制度不完善

建设工程承包人停工权，即承包人在停工事由出现后，为维护自身的权益，将建设工程的部分或全部工作暂时停止的权利，从合同履行的角度来看应为合同履行中止。但我国《合同法》只在第 68 条规定了合同履行中止的情形：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：㈠经营状况严重恶化；㈡转移财产、抽逃资金，以避免债务；㈢丧失商业信誉；㈣有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形”，而第 66、67 条规定的是“有权拒绝其履行要求”。值得注意的是，“拒绝其履行要求”至少包含两层含义：一是对方要求其履行。例如买卖双方签订采购合同，约定买方 1 月 1 日付款，卖方 1 月 30 日交货，买方未能如期付款时，依据《合同法》第 66、67 条的规定，卖方无权中止备货行为，只有待交货期限届满后才能应买方的交货要求而拒绝履行；二是享有抗辩权的一方享有的是拒绝履行权而非中止履行权，对于一次性给付的合同，拒绝履行是恰当的，但对于持续性履行合同，中止履行的说法更贴切。建设工程合同的履行过程是一个持续的过程，在这个过程中，发包人和承包人履行合同义务的顺序交错相继，如果严格解释《合同法》第 66、67 条的规定，将会导致承包人等到工期届满，发包人要求交付工程时才可以行使抗辩权，而此时承包人再停工已没有任何意义，因此有必要将中止履行的范围扩大到同时履行抗辩权和后履行抗辩权。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.1.6 停工权限制的缺失

任何权利的范围如果过于膨胀，其性质即会发生恶化，从一定角度讲，范围恶性膨胀的权利的行使，较之不履行义务的行为所给他人权利造成的损害更大。[19]由于停工权是一项私力救济权，因此如果允许承包人随意行使停工权，不仅有违停工权的立法宗旨，而且将会造成他人权利随意被侵害的恶果。

发包人在履行合同过程中存在违约行为的，承包人可行使停工权，但这并不意味着发包人违约情形如何，承包人都可以行使停工的权利，否则停工权的滥用就会导致合同无法得到履行，违背诚实信用原则，也与法律设立抗辩权制度的宗旨相背离。建设工程合同的履行过程是一个复杂、长期的过程，在这个履行过程中难免会出现不适当履行的情况，例如发包人迟延交付图纸几天，但迟延交付的部分图纸不影响正在进行的施工，此时若承包人以此为由停工，显然有违诚实信用原则，不利于商品经济的发展。有鉴于此，有必要对停工权的行使给予一定的限制，包括对停工权的行使原则、条件、程序等做出进一步规定，以平衡双方当事人的利益，体现“法的善良与公正”。

3.2 示范文本通用条款

发包人和承包人依法签订的施工合同是具有法律意义上最高优先地位的合法文件，是为实现建设目标，明确相互权利、责任、义务关系的协议。我国现行的 GF—1999—0201《建设工程施工合同（示范文本）》（以下简称《99 版施工合同》）是国家建设部、国家工商行政管理局于 1999 年 12 月 24 日联合颁发的，该示范文本对规范施工合同当事人双方的行为，解决施工合同中长期存在的合同文本不规范、条款不完备、合同纠纷多等问题起到非常明显的作用。目前国内的各类公共建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装所签订的合同，基本上是按照上述示范文本执行的。

《99 版施工合同》通用条款第 24 条规定：“实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间 7 天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后 7 天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。”第 26.3 条规定：“发包人超过约定的支付时间不支付工

[19] 费安玲．论保证人的抗辩权[J]．政法论坛，2000（1）.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起计算应付款的贷款利息。”第26.4 条规定：“发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。”示范文本的通用条款规定了发包人欠付工程预付款及进度款时承包人有权停工，但对于上述条款，笔者认为仍存在以下缺陷。

3.2.1 没有强制性

《99 版施工合同》分为协议书、通用条款和专用条款三部分，但这三部分不是各自独立的，而是互为说明、互为补充。《协议书》作为总纲性的文件，概括了双方的基本权利和义务，目的是说明合同涉及的主要内容，确认合同文本的组成文件；通用条款是施工合同示范文本的主要部分，规定着共性方面的问题；专用条款的双方之间的个性化特殊约定，是对通用条款的补充，在解释顺序上，两者不一致时，专用条款优于通用条款。因此，在签订施工合同时，许多发包人借助其优势地位，在专用条款内强行排除上述关于停工权的通用条款的适用，使该条款形同虚设。

3.2.2 可停工范围过于狭窄

在施工合同的履行过程中，发包人承担的合同义务不是单一的，而是复杂多样的，其中主要包括按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地、技术资料、资金等，发包人未按合同约定履行上述义务的，承包人都有权行使停工权。《99 版施工合同》只规定了发包人未按照约定支付工程预付款和进度款时，承包人有权停工，对其他发包人的违约行为则没有予以规定，规定的范围过于狭窄。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章　完善我国建设工程承包人停工权的构想

4.1 确定承包人停工权行使的原则

4.1.1 诚实信用原则

诚实信用原则是维持当事人双方之间以及他们与社会之间的利益平衡的立法者意志。[20]它起源于罗马法中的诚信诉讼。[21]我国《民法通则》第 4 条规定，“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”；《合同法》第 6 条规定，“当事人行使权利、履行义务应当遵守诚实信用原则”。这两个条文是诚实信用原则在我国民法中的体现，诚实信用原则要求民事主体在民事活动中讲求信用，恪守诺言，诚实不欺，在追求自己利益的同时不得损害他人和社会利益，要求民事主体在民事活动中维持双方的利益及当事人利益和社会利益的平衡。

由于诚实信用原则功能在实践中的凸显，诚实信用原则被奉为现代民法的最高指导原则，学者谓之“帝王条款”，所有具体的民事立法均不得违反该原则或对该原则有所保留。诚实信用原则是民法的基本原则，也是合同当事人行使抗辩权应当遵守的基本行为准则，大陆法系认为，行使抗辩权要受到诚实信用原则的限制。如果一方的违约在性质上和后果上是轻微的，则另一方在此情况下援用抗辩权，拒绝对方的履行，并拒绝履行自己的义务，就根本违背诚实信用原则。因为抗辩权制度的设立目的就在于维持双方当事人之间的利益平衡，所以这种利益平衡的维持就应当以诚信原则作为指导。如果发生双方当事人之间利益关系失衡的情况，就应当加以调整，以使失衡的利益达到平衡。另外，如果对抗辩权不加以限制，一方当事人动不动就以抗辩为由不履行合同义务，必然会导致合同纠纷不断，损害对方当事人的利益。因此，当事人必须正当行使抗辩权，不得滥用该权利，致对方以损害。[22]何孝元先生认为：“亦如一般权利之行使，欲受诚信原则之支配而不得滥用，故倘若他方当事人已为部分之给付时，依其情形，如拒绝自己

[20] 柳经纬主编．民法总论[M]．厦门：厦门大学出版社，2005：29

[21] 在罗马法里，诉讼有严格诉讼和诚信诉讼之分。在严格诉讼中，承审员只能依照合同的条款进行裁断，不得予以变更。在诚信诉讼中，承审员不受合同条款字面含义的约束，可根据公平原则，按照通常人的判断标准增减当事人的义务。这种诉讼因在诉讼请求中表明“依诚信”（ex fide bona）而得名。

[22] 汪渊智，李志忠．抗辩权略论[J]．福建政法管理干部学院学报，2003（3）．

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

之给付有违诚实及信用方法者，则不得拒绝自己之给付。”[23]日本学者渡边达德也认为：“只有小部分没有履行是否行使同时履行抗辩权？依诚信原则来看，一是看此物是否可分，二是按公平原则、诚实信用原则行使同时履行抗辩权。”[24]

在建设工程施工过程中，承包人行使停工权应当符合诚实信用原则，因为建设工程施工具有投资大、周期长，涉及的主体多等特点，建设工程施工合同的履行过程中，双方当事人都难免会出现履行不当的情况，如果发包人一出现履行不当的情形，承包人立即采取停工，这显然有违停工权制度设立的宗旨。事实上，如果承包人在行使停工权的时候没有遵循诚实信用原则，将会造成灾难性的局面。因为法律不可能完整列举承包人行使停工权的情形，当法律出现漏洞时，承包人不遵守诚实信用原则，随意停工，必然给发包人甚至社会带来巨大的经济损失。因此，笔者认为在立法确认承包人的停工权的基础上，应当以诚实信用原则作为其指导原则，平衡发包人与承包人之间的利益，促进施工合同的顺利履行。

4.1.2 权利不得滥用原则

权利不得滥用原则又称为权利滥用的禁止原则，或禁止权利滥用原则，是指在行使权利的时候，外观上徒具权利行使的形式，而就具体而言，实质上违反权利之社会性，不能承认其为权利行使的行为。在大陆法系国家，权利不得滥用原则是诚实信用原则的当然内容，或者说是诚信原则的反面规范，即权利之行使有违诚信原则者，构成权利滥用。[25]社会主义国家多将权利不得滥用原则从诚信原则中独立出来，以减少诚信原则的非直观性，我国亦是如此。[26]我国《宪法》第 51 条规定：“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利”，该条文是权利不得滥用原则的宪法基础。《民法通则》第 7 条规定：“民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益，破坏国家经济计划，扰乱社会经济秩序”，该条文是权利不得滥用原则在民法中的体现。

建设工程活动是一项与公共利益紧密联系的活动，建设工程活动所形成的建筑物、

[23] 何孝元：《诚实信用原则与衡平法》，三联出版社，年版。
[24] 韩世远，下森定．履行障碍法研究[M]．北京：法律出版社，2006：329
[25] 陈钪雄．民法总则新论[M]．台北：三民书局 1982：920
[26] 柳经纬主编．民法总论[M]．厦门：厦门大学出版社，2005：31

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

构筑物等是人们日常生活和生产、经营、工作的主要场所，建设工程的质量与普通大众的生命财产安全息息相关。建设工程活动在实施过程中，还会对周边的公共环境、卫生、交通、安全产生影响，因此各国法律对此都有严格的规定，以维护公共利益。在某些特定条件下，承包人暂停施工不仅会对发包人造成影响，也会对社会公共利益造成损害。例如，一项房屋建筑工程基础开挖施工，施工正进行到搭建护壁支架阶段，此时若承包人停工，停止搭建护壁支架，则有可能导致周边的地块塌陷，造成难以挽回的损失；又如，在水利改扩建工程中，由于承包人停工，导致工程未能在雨季来临前完工，此时若发生洪涝灾害，水利工程不能发挥其排洪排涝的功能，将会严重威胁人民群众的生命财产安全。因此，承包人在行使停工权的时候要考虑是否违反了社会公德、社会公共利益、国家经济计划、社会经济秩序等，否则就构成了权利滥用，其停工权的行使不仅不受法律保护，并且还应当依法承担相应的法律责任。

4.1.3 减损原则

减损原则又称减轻损失规则，指受害人不得就其本可以采取合理措施予以避免的财产损失获得赔偿。[27]我国法律对减损原则的具体表现为，《民法通则》第 114 条和《合同法》第 119 条的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

减损原则最初是从英国普通法上发展出来的，现在已为许多国家的立法和判例普遍采用，在英美国家，减轻损失规则（mitigation of losses）源远流长。“早在 1677 年，在英国的 Vertue v. Bird 一案中，该规则已初具雏形，原告按照与被告的合同将货物送到一个叫埃普斯维斯（Ipswith）的地方，并交到原告指定的地点，但到达埃普斯维斯以后，被告在指定地点时迟延了 6 个小时，由于原告的马很热，又站在一个不合适的地方，不久就死掉了。原告为此请求被告赔偿损失，法院驳回原告的赔偿请求，理由是“让马站着是原告的蠢行”，因为他“本来可以将马解开，或者将货物卸在埃普斯维斯的任何地方”。此后历经发展，形成了成熟的减轻损失规则。”[28]

“减损规则直接影响到受害人所可获得的损害赔偿的范围，而该规则的适用则要看受害人是否及时采取了减损措施，其核心就是要看受害人是否合理地作为或者不作为

[27] 马俊驹，余延满．民法原论[M]．北京：法律出版社，2007：630
[28] 孔祥俊．合同法教程[M]．北京：中国人民公安大学出版社，1999：488

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了，因而我们可以说减损规则的关键在于判断受害人行为的‘合理性’上。”[29]一般来说，对于确定受害人采取的措施是否合理或适当的标准，应以受害人主观上是否处于善意为根据，主要考查考虑以下几个因素：第一，受害方的减损措施是否达到了人们处理同类情况的通常采取的普通措施，如果没有达到普通措施的程度，可以考虑其具有疏忽或者懈怠；第二，采取的普通措施是否具有难以克服的困难，如果存在难以克服的困难，则不能勉为其难；第三，受损害方对防止损害扩大的主观态度。

减损规则是一种激励受害方按经济效益的方式行事的规则，它促进资源的有效配置，鼓励受害方有所作为，这不仅是维护了债务人的利益，也维护了社会整体利益，避免了社会财富的减少。对于承包人而言，其在发包人违约的情形下行使停工权，应当充分考虑减损原则，只有这样，才能使发包人违约的浪费性结果最小化，促进社会整体效益的提升。例如，发包人未能按合同约定提供图纸，此时承包人可暂停与迟延交付的图纸相关的部分工程，而不应当将工程全部停工；又如，发包人提供的材料不符合要求，发包人应立即通知发包人更换，而不应马上采取停工措施；而对于一些辅助性的用量不大的材料，如发包人在接到通知后未及时作出指示，承包人也可以自行采购以避免停工。因为工程一旦停工，会给发包人造成更当的经济压力，也会给社会带来负面的影响。

4.2 完善承包人停工权的若干建议

4.2.1 扩大承包人停工权行使的范围

本文讨论的承包人停工权系指在发包人违约时，承包人行使的抗辩权，因此承包人停工权行使的范围就与发包人的违约行为有着密切的联系，以下笔者主要研究发包人哪些违约行为可以成为承包人行使停工权的理由。

4.2.1.1 发包人的合同义务

建设工程施工合同的特点决定了发包人合同义务的多样性、复杂性。根据我国建设工程施工合同的特点，发包人的合同义务主要有以下几项：

★开工前的主要义务。施工前的准备工作，是整个工程建设过程中的重要组成部分，是保证工程建设按期开工和保证工程质量的一个重要环节，发包人应当按照合同的约定

[29] 魏振瀛主编．民法[M]．北京：北京大学出版社，高等教育出版社，2007：447

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

做好施工前的准备工作，包括：

⑴办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件；

⑵办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续；

⑶确定施工标识。包括确定于建设项目有关的建筑物、构筑物、道路、管线的定位，标示水准点和坐标的控制点；

⑷搞好三通一平。指通路、通水、通电、拆除施工范围内的障碍物，即开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作等；

⑸提供技术资料、组织图纸会审。发包人向承包人提供的技术资料的义务包括提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底等；

⑹按照合同约定的时间和数额支付工程预付款。工程预付款，是指建设工程施工合同订立后，发包人按照合同的约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款，它是施工准备和所需主要材料、构件等流动资金的来源。

★开工后的主要义务

⑴按照合同约定提供材料、设备等。一般来说，材料和设备可以由发包人提供，也可以由承包人提供，如果约定了由发包人提供的，发包人必须按合同约定的时间、标准、数量向承包人提供，否则将会导致承包人无法施工。

⑵按照合同约定提供工程进度款。工程进度款，则指在施工过程中，由发包人向承包人支付的，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。

⑶及时进行竣工验收。无论是隐蔽工程的验收还是工程竣工的验收，发包人在接到承包人关于工程已完工、要求组织验收的通知后，应当在合同规定的时间内提请相关部门、单位对工程进行验收，不得拖延。

⑷正确履行监督职责。建设单位派驻工地的代表应终于职守，支持施工单位项目经理部的工作，及时检查工程质量和进行隐蔽工程、中间工程的验收，及时办理各项签证手续。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

★其他非主要义务。发包人的合同义务除了按照施工阶段划分的主要合同义务，还存在一些非主要合同义务，如保密义务、通知义务等。

4.2.1.2 发包人合同义务的目的

合同一方的义务就是对方的权利，发包人合同义务的设立是为了满足承包人利益的实现，因此根据合同义务设定的目的，我们可以将发包人的合同义务分为主给付义务、从给付义务和附随义务。[30]

主给付义务，简称为主义务，是指合同关系固有、必备，并以决定合同类型的基本义务。[31]就双务合同而言，主给付义务构成双方的对待给付义务。我国《合同法》对建设工程合同的定义是"承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同"，因此进行工程建设是承包人的主给付义务，支付工程款是发包人的主给付义务，两者构成对待给付义务。

从给付义务，简称从义务，是不具有独立的意义，仅具有补助主给付义务功能的义务。其存在的目的，不在于决定合同的类型，而在于确保债权人的利益能够获得最大满足的义务。[32]从给付义务的发生可能基于法律的明文规定，或当事人的约定，或基于诚实信用原则及补充的合同解释。如按合同约定的时间和要求提供原材料、场地、设备、技术资料等，属于发包人的从给付义务。

附随义务是指依合同关系发展情形且根据诚实信用原则所产生的为保障债权人给付利益的实现之义务。随附义务的功能有二：第一，促进实现主给付义务，使债权人的给付利益获得最大可能的满足（辅助功能）；第二，维护对方当事人人身或财产上利益（保护功能）。[33] 我国《合同法》第 60 条第 2 款就通常情形列举有通知、协助、保密义务等，[34]因此，发包人在合同履行过程中的通知、协助、保密义务便构成了其随附义务。

合同的主义务、从义务、随附义务三者是即有联系又有区别的，一般来说，合同的主义务与从义务，主义务与随附义务之间是容易区分的，但从义务与随附义务之间的区

[30] 关于合同义务的体系，学者的意见略有不同。一种意见认为：合同义务分为给付义务和附随义务，给付义务包括主给付义务、从给付义务。此外，还有所谓不真正义务或称间接义务。（参见崔建远著《合同法》）另一种意见认为："在附随义务中，存在两种类型：一是可以独立诉请履行的附随义务，即从给付义务；二是不能独立诉请履行的附随义务。不能独立诉请履行的附随义务又可具体分为两种情况：辅助实现债权人给付利益的附随义务和避免侵害债权人人身或财产利益的附随义务。（参见费安玲著《论合同法中的附随义务》）

[31] 崔建远主编．合同法[M]．北京：法律出版社，2007：84

[32] 崔建远主编．合同法[M]．北京：法律出版社，2007：85

[33] 韩世远．合同法总论[M]．北京：法律出版社，2008：215

[34] 《合同法》第 60 条规定："当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。"

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分，存在较大争议。德国通说认为，应当以能否独立以诉请求履行作为判断标准，能够独立以诉请求的为从给付义务，不能够以诉请求的为随附义务。[35]换而言之，从给付是可以请求履行的，随附义务通常仅发生请求损害赔偿的后果。

4.2.1.3 承包人可以行使停工权的情形

不同类型的合同义务有不同的作用，债务人违反不同的合同义务，对债权人也会产生不同的影响。就抗辩制度设置的目的而言，是为了平衡双方当事人的利益，而具体到停工权来说，发包人违反的合同义务应该与承包人的施工义务具有对等性，因此，并非发包人的任何违反合同义务的行为都可以成为承包人行使停工权的理由。前面已经论述过发包人违约与承包人停工权的衔接点，只有当发包人违反合同义务影响了承包人合同目的的实现，或直接导致承包人的施工义务客观不能履行时，承包人才能行使停工权。

我国《合同法》第 278、283 条规定了承包人可以停工的情形包括：发包人没有及时检查隐蔽工程、未按照合同约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料。上述规定中发包人未按合同约定的时间和要求提供资金，属于违反了主给付义务，“主给付构成合同的对待给付义务，在对方未为对待给付前，得拒绝履行自己的给付”，[36]承包人可以据此拒绝施工。获得工程款是承包人的合同目的，发包人拖欠工程预付款、进度款影响了该目的的实现，承包人可以行使停工权。

发包人没有及时检查隐蔽工程、未按照合同约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，属于违反了从给付义务，但上述这些从给付义务构成了承包人履约的前提或先决条件，发包人违反上述合同义务直接导致承包人客观的履行不能，因此承包人可依据事实抗辩予以停工。换而言之，发包人若违反了作为承包人履约的前提或先决条件的合同义务时，承包人都享有停工权。

除了上述作为承包人履约的前提或先决条件的合同义务外，发包人违反其他的从给付义务，承包人是否可以行使停工权呢？这个问题上升到法理的层面，即主给付义务和从给付义务是否具有对价和牵连关系，是否可以适用履约抗辩权的问题。“从给付义务是否纳入双务合同履行上的牵连关系，虽有争论，但原则上应采肯定说，尤其是与合同目的的实现具有密切关系的从给付义务，并应就具体案件依双务合同的类型及当事人的

[35] 王泽鉴．债法原理（第 1 册）[M]．北京：中国政法大学出版社，2001：40~41
[36] 崔建远主编．合同法[M]．北京：法律出版社，2007：84．

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

利益状态，依诚信原则加以确定。"[37] 因此，笔者认为发包人若违反的从给付义务与合同目的实现具有密切关系时，应认为该从给付义务与承包人的主给付义务之间具有牵连性和对价关系，承包人可以行使停工权。例如，施工过程中发生图纸变更导致工程量增加，但发包人拒绝给予承包人签证，而签证是承包人获得增加工程价款的依据，发包人拒绝履行此项义务，直接影响到承包人合同目的的实现，承包人可以据此停止施工。

发包人没有履行附随义务，且该附随义务与合同目的的实现没有直接关联的情况下，承包人不得履行抗辩权，不过，如果这两者之间有着密切联系，则承包人享有停工权。

4.2.1.3 小结

根据我国建设工程合同的性质，获得工程价款是承包人的合同目的，因此发包人的主给付义务是支付工程款。当发包人违反主给付义务时，承包人的合同目的会落空或面临落空的风险，因此承包人可以行使履约抗辩权，拒绝履行己方的主给付义务——停止施工。换句话来说，发包人违反主给付义务，未按合同约定支付工程款的，承包人可以行使停工权。

发包人违反从给付义务，承包人并不当然享有停工权，需要先判断该从给付义务的不履给承包人造成影响的性质及严重程度。如果发包人不履行此项义务，会导致承包人的合同目的会落空或面临落空的风险，承包人得以行使停工权；或，如果发包人不履行此项义务，直接导致承包人的履行不能，承包人亦享有停工权。

我国《合同法》第 278、283 条采用列举的方式将承包人停工权的行使范围界定在六种情形之内，但在实际施工活动中，发包人合同义务的具体形态多种多样，个体差异性很大，能够作为承包人行使停工权事由的发包人违约行为绝不应仅限于以上六种。

4.2.2 区分不同性质承包人停工权的实质构成要件

上述关于承包人停工权的范围，主要讨论的是发包人违反哪种义务，承包人可以行使停工权；在这节里，关于承包人停工权的实质构成要件，主要讨论发包人违约到何种程度，承包人可以行使停工权。

承包人停工权依据性质的不同，可以区分为属于履约抗辩权的停工权（权利抗辩）

[37] 韩世远，下森定．履行障碍法研究[M]．北京：法律出版社，2006：264.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和属于事实抗辩的停工权，这两种不同属性的承包人停工权成立的价值基础不同，适用的法律原理不同，因此其实质构成要件也会存在差异。

4.2.2.1 履约抗辩权性质的承包人停工权

我国《合同法》第 66、67、68 条分别规定三种类型的履约抗辩权：同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安抗辩权，这三种履约抗辩的构成要件各不相同。作为履约抗辩权的承包人停工权在具体适用的时候，可以依照上述三种履约抗辩权的构成要件加以判断。

《合同法》第 68 条对不按抗辩权的实质构成要件已规定得很详细，再此不再赘述。同时履行抗辩权和先履行抗辩权中，除了双方合同义务的时间顺序存在差异以外，其实质构成要件是一样的，笔者将其二者一并进行论述。我国《合同法》第 66、67 条都规定了一方不履行合同义务或履行义务不符合约定，另一方可行使抗辩权。具体到承包人停工权来看，即发包人不履行合同义务或履行义务不符合约定时，承包人即可以行使停工权，这是承包人行使停工权的实质要件。在这里，不履行合同义务是容易判断的，但履行合同义务不符合约定时，发包人在何种情形下可以行使停工权，则成为实践中的疑难问题。

履行不符合约定在外延上可包括瑕疵履行、部分履行等情形，我国《合同法》第 66、67 条针对上述履行不符合约定的情形规定了债务人行使抗辩权时，拒绝履行的债务应与债务人履行不符合约定“相适应”。对于瑕疵履行和债务为不可分之债的场合，一方瑕疵履行或不完全履行时,另一方在多大程度上可拒绝履行,并不存在明确的可予以计算的标准。例如，合同约定发包人于 1 月 10 日向承包人支付 100 万元的预付款，但到期后发包人仅支付了 80 万元，则此时承包人是否可以停工？或者停止多大范围的施工才算是与发包人的违约行为“相适应”？

为解决这个问题，德国民法典[38]和我国台湾地区民法[39]引入了诚实信用原则，即当一方当事人部分履行时,另一方当事人并非当然获得拒绝履行的权利,只有其拒绝履行对待给付义务不违背诚实信用原则时,方可拒绝履行。英美法对此则采用类型化处理的方式，如英国法院对提供服务或工作类型的合同，因服务或工作在性质上难以分割履行,

[38] 《德国民法典》第 320 条第 2 款的规定，“另一方当事人已履行部分给付的,根据情况,特别是因迟延部分无足轻重时,当事人一方如果拒绝履行对待给付有违诚实信用原则的,即不得拒绝履行”。

[39] 我国台湾民法第 264 条第 2 款规定，“他方当事人已为部分之给付时,依其情形,如拒绝自己之给付有违背诚实及信用者,不得拒绝自己之给付”。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

适用"实质履行"原则作为判断履行抗辩权的基准，即工作一旦被实质地完成，完成者即可获得对价。美国法将合同区别为可分合同与不可分合同，前者是一个可分开或分期分批履行的合同，后者是一个一次履行完毕的合同。如果履行是可分的，一方存在部分不履行时，另一方只能拒绝履行与未履行部分相当的债务。国外的立法和判例对我国承包人停工权实质构成要件的判定有借鉴意义。

4.2.2.2 事实抗辩性质的承包人停工权

事实抗辩性质的承包人停工权成立的前提条件是发包人违反了作为承包人施工先决条件的合同义务，其实质构成要件是发包人违约致使承包人客观的履行不能。

履行不能作为法律上的概念，并不仅仅指物理上的不能，还指依据一般社会观念或交易观念，不可期待债务人实现其债务的履行。某些场合下，物理上可能的给付，如果根据一般社会观念或者交易观念，其履行需要支出非常不相当的劳力、费用，则可称为履行不能。客观履行不能是相对于主观履行不能而言，史尚宽先生认为"基于事物之原因者，为客观不能。非专属于债务人之给付，其不能基于债务人之原因者，为主观不能"。[40]通说认为，客观不能指给付对任何人而言皆为不能，如发包人不提供场地，承包人无法施工，此基于自然法则；又如，发包人未按约定办理爆破作业许可手续，承包人停止施工，此基于法律的规定；再如，发包人未提供主要原材料，在操作上承包人可以另行购买，但就经济事实而言，增加了承包人的履约成本，亦可认为是客观不能。

4.2.3 统一停工损失赔偿标准

承包人停工权与其他抗辩权不同，它在阻碍承包人承担逾期交工违约责任的同时，也会给承包人自身带来一定的损失。因为工程一旦开工，承包人为了确保工程的顺利进行，必须投入大量的人力物力，比如要聘请管理人员、施工人员，购买、租赁各种建筑材料、机械设备等。工程暂时停工，承包人不可能立即遣散人员、拆除设备、退还材料，因此停工期间承包人仍然要支出各种诸如人工工资、设备租金、材料仓管等费用，这些额外增加的费用就构成了承包人的停工损失。各国的法律和示范合同文本在确立承包人停工权的同时，都赋予了承包人索赔停工损失的权利。如我国《合同法》第 278、283 条规定了承包人有权要求停工损失；FIDIC 合同条件第 16.1 条【承包商暂停工作的权利】

[40] 史尚宽．债法总论[M]．北京：中国政法大学出版社，2000：381

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

则规定了："如果因按照本款暂停工作（或放慢工作速度），使承包商遭受延误（或）招致增加费用……任何此类费用加合理利润应计入合同价款，给予支付"。

我国《合同法》第278、283条规定了当发包人违约导致工程停工的，承包人有权要求赔偿停工损失，第284条除了规定停工损失，还并列规定了倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。倒运、机械设备调迁、材料和构件积压并非特定的法律术语，在工程造价定额里也未见相关表述，在工程建设实践中，倒运损失通常指增加的二次运输费用损失；机械设备调迁损失指机械设备调整搬迁所发生的拆装、运输费用损失；材料和构件积压损失指施工中使用的材料和构件积压造成的仓储保管费和贬值损失。由此可见，倒运、机械设备调迁、材料和构件积压损失应为停工损失的一部分，不应与停工损失并列规定，《合同法》第284条的规定显然是立法与实务脱节的表现。

关于停工损失具体包含哪些项目，我国没有统一的立法，只散见于一些地方行业性的规定，如广西壮族自治区建设厅印发的《广西壮族自治区建设工程计价办法》[41]、四川省建设厅印发的《四川省建设工程工程量清单计价规范实施办法》[42]都对停工损失涵盖的项目有所涉及。另外还有一些省市建设行政管理部门进行了具有前瞻性的尝试，制定了专门针对停工损失计算的办法，如四川省建设工程造价管理总站就一般工业和民用建筑制定了《关于明确零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法的通知》[川建价发（2006）19号]、河南省建设厅印发的《建设工程中途停工损失补偿办法》。

根据相关的法律法规、行业规定，业内普遍认为承包人的停工损失主要包括人工费和机械设备损失两大块，但笔者认为这两部分的损失不足以涵盖承包人停工期间的损失。笔者依据相关的规定，结合在实践中的经验，归纳起来，承包人可以索赔的停工损失有以下几项：

⑴工人工资

工人在停工情况下必然丧失劳动力的使用功效，而作为劳动力使用者的承包人又必须对所使用的人工支付薪酬，因此，必然产生人员停工赔偿或补偿的法律事实。目前国内没有统一的建设工程项目人员停工赔偿或者补偿标准，也未区分主体工程和零星工

[41] 《广西壮族自治区建设工程计价办法》第38条"停工索赔"规定："因发包人原因，造成工程一次性停工超过8小时时，承包人应在事件发生后7天内向发包人提出延长工期、补偿经济损失的索赔报告，以及停工人数与工日数、机械停滞台班等资料，……"。

[42] 《四川省建设工程工程量清单计价规范实施办法》第45条规定："停工索赔按下列程序和方法处理：因发包人原因造成工程一次性停工超过8小时的，承包人应在事件发生后3天内向发包人提出延长工期（或）补偿经济损失的索赔报告以及停工人数与工日数、机械停滞台班、周转材料损失等资料……"。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

程人员窝工，同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员停工损失。在现有状态下通常的人员停工索赔和计算是，只要在确认停工的情况下，结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔。在合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对停工人员工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。有部分省市也对停工人员工资作出了规定，如《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》里规定了停工窝工人工补贴为16元/工日。

⑵机械设备停滞费

承包人在停工情况下，其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置，其机械设备使用功效丧失，在机械设备失去效益功能的情况下，还不可避免地产生设备养护、折旧费用，因此，必然产生机械设备停工赔偿或者补偿的法律事实。众所周知，建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班，“台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段（通常为8小时）费用的，但对于停工机械设备的停工定额台班计价和数量计算却比较混乱，没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准，许多省市也没有制定统一的地方标准，只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准。因此，在司法实践中，在停工事实明确的情况下，如何计算机械设备停滞费会面临尴尬局面。

⑶周转材延期使用损失

承包人在施工过程中还会使用到脚手架，混凝土、钢筋混凝土模板及支架等材料，这部分材料在施工实践中统称为周转材，在实际的施工中，许多承包人通常对周转材采用租赁的方式来使用，工程停工，工期延长，无疑增加了承包人周转材使用的成本。即便周转材是承包人自有的，也会发生周转材的折旧、损耗，这部分的损失也应一并计入停工损失才合理。

⑷管理费

管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，这部分费用包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财务费、税金等费用，工程虽然停工，但承包人对项目的管理工作并未停止，此部分的费用仍在支出。在建设工程造价管理中，管理费的计算通常

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为：管理费=（人工费+材料费+机械费）×管理费率，但在计算停工期间的管理费时，这种计价方式显然是不可行的，因此有必要对停工期间的管理费损失作出专门的规定。

⑸因防止扩大损失而支出的费用

我国《合同法》第 119 条第二款规定：当事人因防止损失扩大而支出的费用，由违约方承担。在建设工程活动中，发包人违约，承包人行使停工权，应当遵循减损原则。例如，停工时间过长的，应当遣散工人，只留工地看护人员；为了避免材料丢失，将工地剩余材料搬移集中管理；对于不宜长时间保留的通用材料，转移至其他工地等，承包人为防止扩大损失而采取上述行为而发生的工人遣散费、材料搬运费、运输费等，属于防止扩大损失而支出的费用，该部分费用应由发包人承担。

法律法规层面除了缺乏对停工损失的具体项目的明确规定以外，对各个项目的计算方式也没有统一的规定，因此，无论在非诉讼事务处理过程中，还是在诉讼案件处理的司法实践中争议颇大，案件处理面临着停工损失索赔法律法规建设滞后的实际问题，以停工损失索赔明细化为目的的立法动议和法制建设具有迫切的现实意义和重大的实际价值。

4.2.4 规范承包人停工权行使的程序

诚如以上分析，施工是承包人在施工合同中的主要义务，承包人一旦停工，将会给发包人带来损失，造成经济上的压力。此外，由于承包人停工权属于私力救济的权利，其行使起来很方便，如果不对其行使的程序作出规范，势必会造成该权利的滥用。从另一个方面来讲，规范承包人停工权行使的程序，也是对承包人的一种保护，因为只有明确的程序指引，承包人才能实现有法可依。

4.2.4.1 明确通知义务

即停工事由发生后，承包人采取停工措施之前，承包人应当向发包人发出停工通知。我国《合同法》第 69 条规定了，当事人依据不安履行抗辩权规定中止履行的，应当及时通知对方，但对行使同时履行抗辩权和后履行抗辩权的，则没有规定通知义务。笔者认为，在建设工程活动中，承包人无论援引何种抗辩权规则行使停工权都应当履行通知义务，因为：第一，通知义务是依据诚实信用原则而产生的重要的附随义务，如承包人未履行通知义务便擅自停工，显然有违诚实信用原则；第二，规定通知义务，是对

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

承包人自身利益的保护。我国《合同法》第283条规定了，发包人违反合同义务致使承包人停工的，可以顺延工期并进行停工损失索赔。那么，停工通知所载明的停工开始的时间点将会对承包人进行工期索赔、停工损失索赔具有重要意义。

此外，还应当要求承包人在停工通知上载明停工开始时的工人人数、机械台班及库存材料数量，以便发包人予以核实，用以计算承包人的停工损失。

4.2.4.2 通知送达的对象

一般而言，通知应以送达对方当事人为生效要件，但在建设工程活动中，送达的对象有其特殊性。我国建设工程实行建设监理制度，即监理单位受发包人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及工程建设合同，对工程建设实施监督管理的制度。在建设监理制下，发包人不再直接与承包人打交道，而是通过监理单位与承包人打交道，发包人和承包人之间相互提出的任何工作要求，均通过监理单位负责送达。因此，承包人的停工通知可以送达发包人，也可以送达监理单位，两者之一予以签收，即可视为有效的送达。此外，该通知应当写明停工的事由、停工的依据、停工拟开始的时间等。

4.2.4.3 宽限期

停工通知应当考虑一个适当的宽限期，这个宽限期包括发包人收到通知、准备履行和回复的时间。例如，FIDIC合同条件规定的宽限期不应少于21天。我国《99版施工合同》规定，发包人不按约定提供预付款的，承包人可在发出通知后7天停止施工，即宽限期为7天。如发包人在宽限期内履行了合同义务，则承包人没有停工的必要。若发包人虽然在宽限期内未能履行合同，但与承包人达成了谅解协议的，可按谅解协议执行，无需停工。若发包人即未履行合同义务，又没有积极与承包人达成谅解协议的，只能说明发包人没有善意去对其违约行为采取补救措施，此时承包人有权在宽限期届满后采取停工措施，维护自己的权益。

4.2.5 对承包人停工权行使的主体不应扩张解释

建设工程承包人停工权行使的主体为承包人，但承包人在不同场合使用的含义有所不同，狭义的承包人指的是与发包人签订施工合同并承担施工任务的主体，广义的承包

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人则涵括了所有在工地进行承包作业的主体。这些主体中的一部分虽然没有直接与发包人发生合同关系，但其在施工活动中的权利义务亦与发包人有着千丝万缕的联系，因此有必要对相关主体的概念进行明晰，以明确哪些主体在发包人违约的情形下享有停工权。

4.2.5.1 总包人

总包人指从发包人处承接一项工程的全部施工任务的主体，在通常情况下，总包人与狭义的承包人具有相同含义。在工程分包的情况下，总包人并不参与分包部分的施工任务，但总包人需对分包人的工作成果承担连带责任，[43]如若发包人的违约行为损害了总包人的利益，构成了停工事由，其依然有权要求分包人停止施工。

4.2.5.2 分包人

分包人指从总包人处分包某一部分工程或某一类专业作业的人，一般指非主体、非关键性工程施工或劳务作业方面承接工程的当事人，它是与总包人是相对的概念。分包人承接工程施工任务必须是经过发包人同意的，这是分包人与下面讲到的实际施工人的区别。

分包人在施工活动中的权利义务由其与总包人签订的分包合同约定，分包人不直接与发包人发生合同关系，一般而言，发包人违约直接损害的是承包人的合同利益，但不排除某些情形下也会损害到分包人的利益。如前所述发包人违反了作为承包人履约前提或先决条件的合同义务时，则会导致承担具体施工任务的分包人无法开展施工，此时分包人依据事实抗辩予以停工并无不妥。

此外，分包人是否可以援引履约抗辩权制度行使停工权？笔者认为答案应该是否定的。首先，因为合同履行抗辩权的基础是双务合同的牵连性，而发包人与分包人之间并不存在对待给付的双务合同。其次，在分包的场合下，发包人——总包人——分包人之间形成了一个完整有效的链接关系，如果发包人的违约行为给总包人造成了损害，进而影响到总包人对分包人的给付，此时分包人完全可以通过对总包人行使抗辩权，而绝无跨过总包人向发包人主张抗辩权的必要。因此，在这种场合合同履行抗辩权的扩张适用

[43] 《中华人民共和国合同法》第272条规定："总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。"

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是大可不必的。

4.2.5.3 实际施工人

实际施工人指的是不具备法律规定承包条件而进行施工作业的主体，包括转承包人、违法分包合同的承包人、没有资质借用有资质的建筑施工企业的名义与他人签订建设工程施工合同的承包人，实际施工人不仅指个人，还可以包括单位或者有资质的单位。[44]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称法释[2004]14号）首创了"实际施工人"的概念，并规定了实际施工人可以直接向发包人追讨工程欠款，[45]法释[2004]14号赋予实际施工人突破合同相对性原则的权利的理由是：承包人将建设工程非法转包、违法分包后，建设工程合同的义务都是由实际施工人履行的，实际施工人与发包人已经全面实际履行了发包人与承包人之间的合同并形成了事实上的权利义务关系。[46]

尽管最高人民法院的司法解释作出了这样的规定，但笔者认为发包人违约的情形下，实际施工人仍不能突破合同的相对性原则对发包人行使履约抗辩权，理由如下：首先，尽管实际施工人与总包人之间的合同是无效的，但发包人与总包人的合同是有效的，对于发包人来说其要承担的违约风险应仅限于上述有效合同的范围，如果允许实际施工人行使停工权直接对发包人进行抗辩，那么就会产生实际施工人要求发包人顺延工期和计赔停工损失的问题，无疑扩大了发包人的风险范围；其次，尽管实际施工人与总包人之间的合同是无效的，但实际施工人仍然可以参照合同约定要求支付工程款，[47]因此实际施工人的权利义务应该以其与总包人签订的合同为限，实际施工人应向总包人行使停工权予以抗辩，并向总包人进行工期和损失索赔。

4.3 立法建议

4.3.1 从《合同法》角度的立法完善

首先，应当在《合同法》中明确承包人的停工权，并采用列举加概括的方式界定承

[44] 朱树英. 工程合同实务问答[M]. 北京：法律出版社，2007：399

[45] 法释[2004]14号第26条第2款规定："实际施工人以发包人未被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。"

[46] 黄松有主编. 最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用[M]. 北京：人民法院出版社，2004

[47] 法释[2004]14号第二条规定"建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。"

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

包人行使停工权的范围。就《合同法》第283条而言，应将发包人未按合同约定提供资金与其他种类型的违约行为区分开来，采用单独列举的方式规定，如："发包人未按合同约定提供资金的，承包人有权停工，并有权要求顺延工期和赔偿停工损失。"对事实抗辩的停工权，建议对停工事由做概括性的规定，如："发包人未按合同约定履行义务导致施工活动无法进行的，承包人有权就相应部分进行停工，并有权要求顺延工期和赔偿停工损失。"

其次，完善同时履行抗辩权和先履行抗辩权的实质构成要件，借鉴英美法类型化处理的判例经验，同时借鉴德国民法的规定，将诚实信用原则引入《合同法》第66、67条的规定予以适用，克服《合同法》规定的严格、僵化。

再次，完善履约抗辩权的中止履行制度，将中止履行制度引入同时履行抗辩权、先履行抗辩权制度中，扩大其使用范围。

最后，应对停工权的行使程序，包括通知方式、通知的内容、通知的宽限期以及通知生效的条件作出明确的规定。

4.3.2 对相关配套规定的立法完善

目前，在建设工程施工活动中，停工索赔的实现一般依赖于合同对停工索赔的约定或建设工程各领域对停工索赔所形成的贯例或行业习惯，更多的是承包人就停工事实提出索赔报告，由发包人或其监理单位审核后以文件或批复方式进行索赔处理。众所周知，停工索赔如明示在合同中且不为法律所禁止，应当具备法律约束力，依约办理方可，但是如果以承包人提交索赔报告，发包人或其监理审核批复方式处理停工索赔就面临着如何理解建筑行业停工损失索赔贯例或行业习惯的问题了。我们知道，建设工程领域就停工损失索赔所形成的贯例或习贯是不成文法，且各建设工程领域又有各自不同的贯例或习惯，无论是在非诉讼活动中处理停工损失索赔，还是在诉讼中处理停工损失索赔，都因法律制度的缺失，面临着实际操作的现实困难。

正如我们在本文中所讨论的那样，建设工程领域停工损失索赔面临着制度建设和规范建设的瓶径性障碍，因此，就停工损失索赔的制度和规范建设就凸显出其重要性和必要性。笔者认为，应当根据我国现行的建设工程行业管理的实际，结合建设工程分类管理的类别，在不改变现有各类建设工程项目定额台班标准和取费依据的情况下，由各类建设工程分类管理的官方机构或部门或者行业协会，专门针对各类建设工程项目的停工损失涵盖的范围作出明确的界定，并明确各类损失的计算方式和计费标准。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结 语

本文以建设工程发包人违约为视角，对承包人停工权进行了研究，并遵循了“是什么”到“为什么”，再到“怎么做”的思维路径，通过对双务合同的牵连性进行分析，界定了发包人违约与承包人停工权的衔接点，进而对承包人停工权的法律性质进行区分，并结合现行法对承包人停工权现状进行剖析，提出了完善我国承包人停工权的构想。

将笔者的基本观点作一总结，那就是：停工权是承包人面对发包人违约时采取的私力救济手段，其根据双务合同的牵连性而生，也因此决定了发包人只有违反了具有牵连性的合同义务，承包人才享有停工权；承包人停工权是依据两种具体类型的合同牵连性而得以存在的，因此承包人行使救济权时所援引的法律原理不同，停工权由此呈现出两种不同的属性，并分别要求不同的实质构成要件。

纵观全文，针对发包人违约引发的承包人停工权，笔者主要解决了以下几个问题：

第一，厘清了发包人违约与承包人停工权的衔接点，为发包人何种违约情形下承包人得以享有停工权提供了双重判断标准：发包人违反的合同义务是否影响承包人合同目的的实现，或发包人违反的合同义务是否构成了承包人施工义务的前提或先决条件；

第二，引入上述判断标准进行分析，否定了承包人停工权具有单一法律性质的理论，揭示了承包人停工权的双重属性：事实抗辩和权利抗辩（履约抗辩权）；

第三，对发包人合同义务进行了梳理，结合上述判断标准界定了承包人停工权行使的范围：发包人违反主给付义务时，承包人享有停工权；发包人违反从给付义务时，如果影响了承包人合同目的实现，或导致了承包人客观的履行不能的，承包人享有停工权；发包人违反随附义务时，一般不作为承包人停工停工事由，但符合上述两个标准的除外；

第四，区分了不同法律性质的承包人停工权的实质构成要件：作为履约抗辩的停工权可参照《合同法》规定的履约抗辩权的要件；作为事实抗辩的停工权则以发包人违约致使承包人客观履行不能为要件；

第五，为避免私力救济的随意性和盲目性，对承包人停工权行使的原则、程序、主体等进行了必要的限制，并尝试对停工损失赔偿建立统一的计算标准。

笔者相信，对建设工程承包人停工权的深入探讨和广泛实践，必将对建设工程合同领域的履约问题产生积极的作用，该制度的适度建立将为解决国内建筑行业存在的痼疾提供一个全新的思路和方案。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

一、著作

[1] 柳经纬主编．民法总论[M]．厦门：厦门大学出版社，2005．

[2] 马俊驹，余延满．民法原论[M]．北京：法律出版社，2007．

[3] 魏振瀛主编．民法[M]．北京：北京大学出版社，高等教育出版社，2007．

[4] 孔祥俊．合同法教程[M]． 北京：中国人民公安大学出版社，1999．

[5] 尹腊梅．民事抗辩权研究[M]．北京：知识产权出版社，2008．

[6] 汪金敏，朱月英．工程索赔100招[M]．北京：中国建筑工业出版社，2009．

[7] 黄强光．建设工程合同[M]．北京：法律出版社，1999．

[8] 佟柔．中国民法学·民法总则[M]．北京：中国人民公安大学出版社，1990．

[9] 张宏生，谷春德主编．西方法律思想史[M]．北京：北京大学出版社，1990．

[10] 崔建远主编．合同法[M]．北京：法律出版社，2007．

[11] 韩世远．合同法总论[M]．北京：法律出版社，2008．

[12] 王利明．合同法研究（第一卷）[M]．北京：中国人民大学出版社，2002．

[13] 韩世远，下森定．履行障碍法研究[M]．北京：法律出版社，2006．

[14] 王泽鉴．债法原理（第1册）[M]．北京：中国政法大学出版社，2001．

[15] [德]卡尔·拉伦茨．德国民法通论[M]．王晓晔等译．北京：法律出版社，2003：330．

[16] 张宏生，谷春德．西方法律思想史[M]．北京：北京大学出版社，1990．

[17] 黄风．罗马法词典[M]．北京：法律出版社，2002．

[18] 何佰洲．工程合同法律制度[M]．北京：中国建筑工业出版社，2003．

[19] [德]迪特尔·梅迪库斯．德国民法总论[M]．邵建东，译．北京：法律出版社，2001．

[20] 朱树英．工程合同实务问答[M]．北京：法律出版社，2007．

[21] 黄松有主编．最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用[M]．北京：人民法院出版社，2004．

[22] 梁文书主编．审理建设工程案件的法律依据[M]．北京：人民法院出版社，2004．

[23] 史尚宽．债法总论[M]．北京：中国政法大学出版社，2000．

二、期刊

[1] 崔建远．履行抗辩权探微[J]．法学研究，2005（3）．

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[2] 韩世远．构造与出路：中国法上的同时履行抗辩权[J]．中国社会科学，2005（3）

[3] 韩世远．减损规则论[J]．法学研究，1997（1）

[4] 孙杰，何佰洲．论建设工程合同履行中的抗辩权[J]．项目管理，2006（2）．

[5] 莫爱新．论民事救济权[J]．石家庄经济学院报，2005（10）．

[6] 党伟．建筑工程承包商停工权权利属性分析[J]．人民司法，2006（4）．

[7] 汪渊智，李志忠．抗辩权略论[J]．福建政法管理干部学院学报，2003（3）．

[8] 费安玲．论合同法中的附随义务[J]．当代司法，1999（3）．

[9] 费安玲．论保证人的抗辩权[J]．政法论坛，2000（1）．

[10] 王葆莳．德国民法典中抗辩概念的发展史[J]．西南政法大学学报，2004（1）．

[11] 廖振翔．浅谈工程中途停工施工单位损失的补偿[J]．黑龙江科技信息，2007（20）．

[12] 王玉华，王玉开，杨庆民．建设工程中途停工损失补偿计算办法的探讨[J]．山西建筑，2007（19）．

[13] 颜军华，张永春．我国建筑工程索赔存在的问题及对策[J]．科技广场，2009（12）．

[14] 蔡祥，王虎．施工企业法律风险防范专题系列之五——抗辩权未及时行使的风险[J]．施工企业管理，2010（5）．

[15] 查旭红．发包人引发合同中止的对策[J]．施工企业管理，2009（9）．

三、学位论文

[1] 谭敬慧．建设工程承包商“停工权”问题研究（硕士论文）[D]．北京：中国政法大学，2008．

[2] 黄延丽．抗辩权概论（硕士学位论文）[D]．重庆：西南政法大学，2006．

[3] 周荧．论抗辩权（硕士学位论文）[D]．上海：华东政法学院，2006．

[4] 王涌．私权的分析与建构（博士学位论文）[D]．北京：中国政法大学，1999．

[5] 自李京法．继续性合同基础理论研究（硕士论文）[D]．北京：清华大学，2003．

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

完成毕业论文写作的过程，恰逢我初为人母之际，盼望已久的小生命的到来占用了我大量的时间与精力，并一度妨碍了论文的写作和修改的进程，但我一直认为她的降临是上天赐给我最宝贵的礼物。

作为一名全职妈妈，同时要兼顾学业，我曾一度感到身心俱疲，几欲放弃，值得庆幸的是在我最艰难的时候，身旁总是有亲人给我支持。感谢我的丈夫，在忙碌的工作之余千方百计地为我分担家务，让我有更多的时间专注写作；感谢我的婆婆，拖着年迈的身体悉心替我照顾幼小的女儿，为我解决后顾之忧；感谢我的父母，总是在身后默默地为我付出。

同时，也感谢为本文的形成给予过帮助的指导老师、授课老师和班主任，正是有了他们的关心和鼓励，我才能顺利完成了本文的写作。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读学位期间发表论文情况

[1] 覃卓君.浅谈我国夫妻财产制的缺陷及立法完善.法制与经济.2011 年第 4 期

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net